

1500351-68.2021.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296017/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 21113846 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 1692/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2296017 - DEL.POL.S.J.DO RIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500351-68.2021.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500351-68.2021.8.26.0613

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296017/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 21113846 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 1692/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2296017 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY APARECIDO ANTONIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de WESLEY APARECIDO ANTONIO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, eis que no 29 de outubro de 2021, por volta

das 06h30, na Rua Alagoas, nº 86, Carlos Cassuci, nesta cidade e comarca, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, guardava e mantinha em depósito 94 (noventa e quatro) porções de haxixe, pesando 53,66 gramas, e 05 (cinco) porções de maconha, pesando 327,36 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de págs. 74/75, veio amparada no Inquérito Policial – Prisão em Flagrante – de págs. 01/92.

O réu apresentou defesa preliminar (págs. 138/140), aduzindo, em síntese, que se reserva no direito de se manifestar sobre o mérito da ação apenas nas alegações finais, quando pleiteará a absolvição do acusado.

A denúncia foi recebida aos 26 de janeiro de 2022, oportunidade em que fora designada audiência de instrução (págs. 91/93). Na oportunidade, manteve-se a prisão preventiva do réu.

Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo e mídia anexada ao SAJ – pg. 192/194.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A materialidade está nas pgs. 102 e 120/123. A autoria é clara. O irmão do réu disse que as drogas estavam no quarto do réu e ele trancava o quarto. Os policiais foram ao local para cumprir um mandado de busca e apreensão implicando um indivíduo chamado Mocoquinha que estava fornecendo arma para roubos na cidade. A mãe do Wesley entregou um simulacro de arma de fogo aos policiais. O acusado confirmou que estava na posse dos entorpecentes. Entretanto, observa-se que da narrativa dos policiais, pela quantidade de drogas e outros elementos é óbvio que o réu estava traficando drogas. Não é verossímil a alegação de que ele mantivesse a balança apenas para pesar o entorpecente. Usuários crônicos de entorpecentes não fazem a medição diária de seu consumo. A grande quantidade de drogas apreendidas. Haxixe não é uma droga comumente encontrada na cidade. Para ter acesso a esse tipo de droga ele não conseguiria nas biqueiras locais e adquiriu a droga para fornecimento. Nas pgs. 33/35 o réu ostenta antecedentes. A pena deve ser exasperada pela quantidade, variedade e também pela espécie de droga – haxixe. O réu é reincidente, o que também veda qualquer benefício legal ao acusado. Pugna pelo regime fechado.

A Defesa, por sua vez, alega a ausência de qualquer prova acerca da intenção do réu em vender a droga apreendida. Ele é usuário, conforme declarou a genitora. A droga haxixe nunca foi apreendida, o que condiz com a declaração de uso do denunciado. A arma de brinquedo foi um presente de sua mãe. O réu era barbeiro, o que justifica a apreensão de dinheiro. O celular estava inoperante. Diante da insuficiência das provas, não há como apontar ao denunciado a autoria de tráfico. Requer a absolvição, pelo benefício da dúvida. O réu não foi encontrado em atividade de traficância. Requer a desclassificação para os moldes do art. 28 da Lei de Drogas.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 13/14), pelo auto de constatação preliminar (págs. 18/19), bem como pelos laudos periciais (págs. 118/123).

Tais documentos demonstram massa líquida dos entorpecentes apreendidos e a quantia em dinheiro apreendida na operação.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

2 -) Das provas da autoria.

Florence Ribeiro Gallego Gomes informa que estavam investigando os roubos que ocorriam no município e disse que a pessoa que fornecia a arma morava no bairro do Cassucci era moreno e tinha apelido de Mocoquinha. Souberam que o indivíduo era o Claudir, irmão do Wesley. O Mocoquinha, na verdade, era o Wesley. Perguntaram se havia algo ilícito no imóvel e o réu assumiu dizendo que sua mãe e irmão não tinham nada a ver com aquilo. Ele indicou onde estavam as drogas. Sobre perfumes, armas e jóias não encontraram. Mas, a mãe falou que o réu tinha uma arma de brinquedo, uma réplica de uma arma de verdade. A arma foi entregue pela mãe dele. A arma era do Wesley, segundo a mãe dele disse. O Claudir era só o irmão. Como o Wesley ficou muito tempo preso, ele não era conhecido das pessoas ali então as informações recaíam sobre o irmão Claudir. Não conhecia o réu, mas a última prisão dele foi por conta do tráfico de drogas. Ele não disse que a droga era para consumo. Ele quis ficar em silêncio. A quantidade era muito grande, impossível para consumo. A quantidade era absurda. É impossível que fosse para uso. A apreensão de haxixe não é comum na comarca. Nem conhecia o haxixe. Ele é feito da seiva da cannabis e tem potência muito maior do que a maconha. É policial há cinco anos e nunca tinha apreendido haxixe aqui. Nas biqueiras aqui nunca viu haxixe. A maior saída é a maconha e cocaína. Tiveram uma apreensão recente com maconha sintética. Nem todas as biqueiras tem variedade de entorpecentes grandes.

Ana Leticia Avelar Zenaro de Souza relata que fez uma operação conjunta com a polícia civil para cumprir um mandado de busca e apreensão. Naquele barulho o Wesley acordou e saiu pela janela. A mãe dele deixou entrarem. Ele voltou e perguntaram para ele se havia droga na casa e ele indicou. A mãe dele falou que tinha dado uma arma de brinquedo para o Wesley, mas que estava guardada. A mãe dele entregou a arma e disse que era do réu. Ela falou que tinha dado de presente para ele. O Claudir não falou nada. Acharam que era o Claudir, mas no local descobriram que era o Wesley. Ele mesmo se identificou como Mocoquinha. As denúncias indicavam um tal de Mocoquinha. Ele não disse que as drogas eram para o uso. Ele falou que era dele apenas para tirar o irmão e a mãe da situação, mas não falou que era para consumo. É policial há três. Está há oito meses. Nunca apreendeu haxixe em outra situação. Para os padrões de Rio Pardo a quantidade de droga é grande. A mãe dele falou que o Wesley era usuário sim, mas ela não sabia da quantidade que tinha. Ela não entrava no quarto dele. Havia utensílios para cortar cabelo lá. Ele falou que estava fazendo esse tipo de serviço. A balança ele não disse para que usava. Ele falou que o dinheiro era de corte de cabelo. Foi o que ele disse no dia.

Claudio da Silva Ortiz informa que estava em casa no dia e os policiais acharam a droga no quarto do Wesley. Estava o depoente, o réu e a mãe de ambos. Estava dormindo e não sabe o que ele disse. Ele assumiu, falou que era tudo dele. Não tinha visto o simulacro de arma de fogo, nem a balança na casa. O réu não disse que

ia guardar a droga lá. O quarto dele é separado. Os policiais entraram no quarto do depoente e não acharam nada. Ele trancava o quarto. Ele saía de casa, trancava o quarto e levava a chave com ele. O réu cortava cabelo em casa mesmo. Depois da prisão nunca mais viu ele e não teve notícias. Não conhece o apelido do seu irmão. Os policiais disseram que ele tinha apelido do Mocoquinha, mas nunca ouviu tal apelido.

O réu, Wesley Aparecido Antonio em seu interrogatório, afirmou que está bem na prisão. Tem 26 anos. Foi preso anteriormente por tráfico e roubo. Fazia 4 meses e alguns dias que tinha saído da cadeia. Foi preso muito jovem, desde os 18 anos. Na primeira vez ficou 5 anos. Saiu, num intervalo de 5 meses ficou preso e foi absolvido. Tinha curso de corte e modelagem de cabelo, trabalhava na roça, participou de curso na Câmara Municipal. Estava morando com sua mãe e o seu irmão Claudir. Sempre morou em Mococa. Para afastar das amizades resolveu vir para São José porque não queria mais aquela vida. Os policiais lhe chamam de Mocoquinha. Não estava vendendo droga não. Negou os fatos para os policiais, mas quando viu Claudir sendo algemado, ficou desesperado. Os policiais disseram que estava lá por causa de denúncia de droga e não de armas. Falou para o policial que havia drogas no seu quarto. A investigadora achou simulacro de arma e dinheiro que era do corte de cabelo. Pediu para que deixassem o dinheiro para sua mãe. O policial ficou arrogante, prepotente e não quis ouvir. A droga era sua para seu consumo. Pagou R\$ 600,00 na maconha e R\$ 800,00 no haxixe. Nunca foi internado por causa de droga. O simulacro de arma estava lá fazia um tempo. Estava lá sim, mas desconhece. Sua mãe tinha comprado para seu irmão, quando era pequeno. Tinha caixa, estava quebrado e tinha nota. A droga, para não correr risco de ficar indo várias vezes buscar, comprava droga para durar dois meses. Era fim de ano e pegou a droga para não faltar no fim de ano. Sobre a balança controlava a droga que usava. Usava cinco gramas todo dia. É muito difícil para dormir e usava a droga para dormir. Colocava haxixe para ficar um pouco mais forte. A investigação foi por conversa alheia porque o depoente queria tirar seus documentos novamente. Foi na delegacia para tirar seu RG dias antes. Tráfico não existe. Apenas assumiu que a droga estava lá para não complicar as pessoas da sua casa. Pede ajuda em relação ao uso da droga. Teve condenações por erros no passado e viveu vários anos no presídio e não queria mais isso. Por isso estava trabalhando. A denúncia que ocorreu e o que foi achado, não havia relação com tráfico. O curso que participava do programa meu emprego era na câmara municipal, do lado do fórum. Conseguia R\$ 1600,00 por mês e comprou móveis. Da última vez foi absolvido por causa de situação de armas, roubos. Na primeira vez o próprio depoente ocasionou a prisão. Não é traficante e foi tratado com arrogância. Sabe que o tráfico prejudica a saúde pública e a droga estava prejudicando apenas a sua própria saúde. Deixava seu quarto fechado a todo momento e é uma pessoa muito fechada.

3 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos.

Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que contemplar violação ao princípio da igualdade tratando diversamente o valor de uma testemunha por sua profissão, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a “lei do silêncio”, extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

Nada faz crer que os policiais pudessem ter consigo 94 (noventa e quatro) porções de haxixe, pesando 53,66 gramas, e 05 (cinco) porções de maconha, pesando 327,36 gramas, para indevidamente "forjar" cidadãos, colocando suas carreiras em risco a fim de aprisionar pessoas com as quais não mantêm qualquer desafeto ou problema pessoal.

O réu, a seu turno, não declarou qualquer inimizade ou explanou situações concretas que pudessem indicar que os policiais em questão estariam simplesmente a elucubrar versão incriminadora para lhe prejudicar.

Em sentido oposto, confirmou que as drogas lhe pertencem, embora tenha indicado destinação diversa daquela que vem exposta na denúncia, ou seja, seu próprio consumo.

Tem-se, portanto, de um lado, as versões uniformes e harmônicas dos policiais e de outro lado a mera negativa do réu.

Com efeito, a dúvida capaz de favorecer o réu deveria estar sustentada em contraprovas e não meramente a partir de argumentações, sob pena de contemplar-se indevidamente a subjetividade e o "decisionismo".

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEI MALATESTA, o qual afirma que "o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 - destaque do Juízo).

A verdade processual obtida vem no sentido de que as acusações ministeriais estão evidenciadas em sólidos depoimentos dos policiais (civis e militares), além dos laudos que atestam a materialidade delitiva.

Nada confirma que o simulacro de arma de fogo pertencesse ao irmão do réu. Este foi inclusive ouvido como testemunha e não chegou a apresentar tal versão. Apenas confirmou que as drogas estavam no quarto do réu e que desconhecia as atividades ilegais do irmão.

O fracionamento das porções de haxixe em quase uma centena (94 porções) deixa evidente o propósito mercantil da conduta sendo certo que o réu não guardava a droga apenas para seu uso pessoal.

Registre-se que ainda que admissível a circunstância de que o réu padeça de toxicomania, a alegação de ser usuário de droga tem-se que em nada modifica a imputação, pois perfeitamente conhecida a figura do viciado-traficante" (STF-2ªTurma, HC-MC73.197/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 22.11.1996).

Sobre a questão já se manifestou o E. TJSP: - "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP101/498).

Diante de tal panorama, não se ressente este Juízo de qualquer dúvida a respeito da procedência da ação penal.

Presente a tipicidade delitiva na forma capitulada na denúncia e não havendo

justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

4 -) DO VEREDITO, DOSIMETRIA DA PENA e DEMAIS DETERMINAÇÕES:

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 74/75, para CONDENAR WESLEY APARECIDO ANTONIO pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, passando a dosar-lhe a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 50,8 gramas de haxixe e 312,10 gramas de maconha, conforme apontado no laudo pericial de págs. 118/123.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

A quantidade-massa é suficiente para justificar acréscimo. Da mesma forma, a quantidade-diversidade justifica acréscimo (total de 362 gramas de droga), visto que ele tinha em depósito mais de um tipo de ilícito, podendo, assim, atingir maior clientela.

A quantidade-diversidade (duas drogas), também é hábil a legitimar acréscimo, pois havendo duas drogas à disposição do réu ele ostenta maior periculosidade na medida em que pode alcançar maior clientela.

No caso concreto, não pode ficar sem proporcional reprovação o fato de que o réu tinha consigo droga raríssima, jamais apreendida em São José do Rio Pardo por ambas as policiais que testemunharam e que este magistrado, há seis anos na jurisdição criminal nesta comarca, também não se recorda de outro caso de tráfico com apreensão de haxixe.

A espécie de droga é incomum e recomenda maior rigor na reprimenda, pois o réu deve ter empreendidos esforços consideráveis para obter droga "nova" que pudesse despertar o interesse da "Freguesia" local.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram

graves.

O réu ostenta maus antecedentes. Foi condenado nos autos do processo » Foro de Mococa - 2ª Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0007562-62.2014.8.26.0360 (0003588-60.2015.8.26.0496) à pena de sete anos e seis meses de reclusão em regime fechado, com trânsito em julgado para a defesa aos 15.06.2015 – pg. 34.

Assim, fixo a pena base para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, 3/6 ou metade acima do mínimo legal, sendo o acréscimo de 1/6 pela quantidade-massa de drogas; 1/6 pela variedade e especificidade do haxixe e 1/6 pelos maus antecedentes, totalizando 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

O réu é reincidente específico. Além do processo supra mencionado para fins de maus antecedentes, há a condenação nos autos Foro de Mococa - 2ª Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0007401-52.2014.8.26.0360 (0002859-56.2015.8.26.0521) em que lhe foi imposta a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa em regime fechado por tráfico de drogas. Trânsito em julgado ocorrido aos 08.07.2016 – pg. 33.

Agravo a pena em mais 1/6, guindado-a ao patamar de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Ausentes causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena, pois o réu não pode ser beneficiado com a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante dos maus antecedentes e reincidência específica.

Torno em definitiva a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa, estes calculados na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, cada dia-multa, conforme artigo 43 da Lei de Drogas.

Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento de pena, em consideração ao montante de pena aplicada e à reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", c.c. art. 59, todos do Código Penal.

Tendo em vista o montante de pena aplicado, bem como a reincidência, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Porém, sendo patrocinado por advogado dativo, defiro-lhe os benefícios da assistência judiciária para suspender a cobrança deste ponto da condenação, na forma do § 3º do art. 98 da Lei 9.099/1995.

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do réu, mantenho sua custódia cautelar, indeferindo a pretensão de apelar em liberdade. Como visto, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente específico. Tinha consigo grande quantidade de drogas e uma delas bastante rara, fracionada em quase uma centena de invólucros.

O periculum libertatis é evidente, devendo o réu permanecer encarcerado sob pena de que com o seu retorno precoce ao mesmo ambiente que o levou a delinquir, a sociedade veja-se desprotegida em desatenção às lições que podem ser extraídas da criminologia, especialmente da ecologia criminal preconizada pela Escola de Chicago.

Em seu conhecido ensaio sobre os Fundamentos do Direito, Leon Duguit assevera que "O homem em sociedade tem direitos; mas esses direitos não são prerrogativas pela sua qualidade de homem; são poderes que lhe pertencem porque, sendo homem social,

tem obrigações a cumprir e precisa ter o poder de cumpri-las. Esses princípios diferem da concepção do direito individual. Não são direitos naturais, individuais, imprescritíveis do homem que fundamentam a regra de direito imposta aos homens em sociedade. Mas, ao contrário, porque existe uma regra de direito que obriga cada homem a desempenhar determinado papel social, é que cada homem goza de direitos – direitos que têm assim, por princípio e limites, o desempenho a que estão sujeitos. – Duguit, Leon, Fundamentos do Direito. Martin Claret : São Paulo, 2009, pg. 47

A liberdade deve ser compreendida como liberdade de cumprir o seu dever social, pois o homem só possui liberdade de desenvolver suas atividades enquanto consagra seu exercício à realização da solidariedade social.

A noção de direito fundada na ideia do dever difundiu-se a partir de Augusto Comte que assim concebeu: "A regeneração decisiva consistirá sobretudo em substituir sempre os direitos pelos deveres, para melhor subordinar a personalidade à sociabilidade. Só pode haver verdadeiros direitos na medida em que os poderes regulares emanavam de vontades sobrenaturais. Para lutar contra essa autoridade teocrática, a metafísica dos cinco últimos séculos introduziu pretensos direitos que só comportavam um papel negativo; quando se tentou dar a eles verdadeiro sentido orgânico, depressa manifestaram tais direitos a sua natureza anti-social pela tendência a consagrar sempre a individualidade. Todos têm deveres para com todos, mas ninguém tem direito algum propriamente dito. Ninguém possui outro direito que não seja o de cumprir sempre o seu dever. (Auguste Comte – Politique Positive – 1890, 1, p. 351.)

A noção individualista de direitos é incompatível com o objetivo fundamental da Constituição de construir uma sociedade "livre, justa e solidária".

O direito à segurança, previsto no artigo 5º, caput, da Constituição da República e também no artigo 6º da Norma Fundamental, por vezes tem sido esvaziado por linha retórica que vem ocasionando distorção do necessário garantismo penal.

Não parece que a Constituição da República tenha concebido uma liberdade ilimitada, em detrimento de outros tantos Direitos Fundamentais de igual estatura.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 dispõe no Art. XXIX:

O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade.

No exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática.

Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente e aos fins e aos princípios das Nações Unidas. (destaques do Juízo).

Não há dúvidas de que "os deveres para com a comunidade" e "respeito dos direitos e

liberdades dos outros" têm sido também desconsiderados, bem como o fato de que os direitos e liberdades não podem ser exercidos em detrimento da própria proteção dos Direitos Humanos dos outros humanos.

O item 2 supra demonstra que todo homem está passível de limitações estabelecidas em lei para satisfazer as exigências da "ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática" de modo que a prisão cautelar no presente caso está plenamente justificada e não representa qualquer violação aos Direitos Humanos.

Ao revés, a prisão cautelar de Wesley Aparecido Antonio vem exatamente preservar os Direitos Humanos de toda a comunidade rio-pardense

Portanto, a prisão cautelar é medida indispensável no caso concreto.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória.

Patrocinado por advogado dativo arbitro os honorários, conforme regras do convênio. Oportunamente, expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

- 1 -) Expeça-se guia de execução definitiva;
- 2 -) Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;
- 3 -) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
- 4 -) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;
- 5 -) Como a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva, decreto seu perdimento, nos termos da lei.
- 6 -) A incineração das drogas foi autorizada nas pgs. 53.

P.I.C

Sao Jose do Rio Pardo, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA